

1500490-78.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500490-78.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-78.2021.8.26.0626 - Controle nº 2022/000050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLADAUBERTO LIMA DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 126/127, no dia no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 22:00 horas, na Rua Tropicanga, nº 440, bairro Boiçucanga, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, CLADAUBERTO LIMA DA SILVA, qualificado à fl. 10, e GUILHERME ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado à fl. 12, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico de drogas, 06 porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso bruto de 30,45g, 22 papелotes de cocaína com peso bruto de 28,16g, 43 microtubos de cocaína com peso bruto de 65,95g e 125 trouxinhas de papel de cocaína na forma de crack, com peso bruto de 32,32g, além da quantia de R\$ 120,00, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 11.

Em razão destes fatos, os réus CLADAUBERTO LIMA DA SILVA, qualificado à fl. 10, e GUILHERME ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado à fl. 12, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06 c.c. artigo 29 do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 144/145) e os réus citados (fls. 178 e 181).

Sobreveio resposta à acusação (fls. 191/192 e 200/205), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 212/213).

Houve a realização de audiência de instrução (fls. 247/251, 271 e 333/334), com a oitiva de duas testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em audiência de instrução, pela Defesa foi feito o pedido de liberdade provisória do réu Cladauberto, o que foi indeferido pelo juízo considerando que os motivos que fundamentaram a prisão encontravam-se inalterados e que não havia excesso de prazo. Em debates de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas em concurso de agentes, nos exatos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais, ouvidos em juízo.

Ao passo que a Defesa, em alegações finais pugnou pela absolvição do réu Cladauberto, considerando ser o mesmo usuário de drogas, e com relação ao réu Guilherme, que confessou a traficância, requereu na terceira fase a aplicação da atenuante do privilégio, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/07), laudo de constatação (fls. 16/17), relatório policial (fls. 107/108), laudo químico toxicológico (fls. 188/190) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre os réus.

O policial militar Osmar Barros Domingues, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que estavam em operação conjunta com outra equipe, sendo que viram dois indivíduos correndo, saindo de uma mata. Houve a abordagem, encontrando com os mesmos: 3 papелotes de cocaína e dinheiro com Cladauberto e 3 papелotes de crack e dinheiro com o Guilherme. Os réus admitiram estar traficando, indicando o local onde se encontrava o restante das drogas. Disse que Cladauberto era conhecido nos meios policiais, tendo passagem por furto e tráfico, inclusive. O Guilherme era conhecido no local como "olheiro", tendo passagem apenas por furto. Às reperguntas da Defesa disse que o Cladauberto indicou o local onde estaria guardado as drogas, sendo que somente os dois estavam no local. Disse, ainda, que não há como afirmar que um dos dois era usuário, considerando que houve confissão. Disse que não houve agressão, mas houve uso de algema para segurança da equipe. O policial militar Luiz Daniel Cipolari, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que se recorda parcialmente dos fatos. Disse que estava subindo a rua quando outra viatura estava fazendo incursão. Quando os réus viram a viatura, tentaram fugir. Ambos os réus estavam com drogas nos bolsos e estavam fazendo a venda. Depois, vieram mais policiais, que ficaram na segurança. Não havia transeuntes no local. A sacola com as demais drogas foi encontrada próxima a uma madeira, mas não sabe indicar se foram os réus quem indicaram o local. O réu Cladauberto é conhecido nos meios policiais. Foi encontrado dinheiro com um dos réus, decorrente da venda de entorpecentes. Às reperguntas da Defesa disse que trabalha na região há aproximadamente um ano, sendo que nunca presenciou os réus nos bares usando drogas.

O réu Cladauberto Lima da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que foi apenas comprar drogas. Disse que estava trabalhando numa pousada perto do local dos fatos e que os amigos o chamaram para ir comemorar aniversário dele. Durante a comemoração, o pessoal começou a beber e o réu saiu para comprar drogas. Quando viu os policiais, o rapaz que vendia as drogas saiu correndo, mas o interrogado deitou no chão. Ambos os réus foram levados para delegacia, depois um dos policiais foi até a residência do réu. Às reperguntas da Defesa disse que mostrou aos policiais apenas os pinos que comprou e o dinheiro que tinha recebido

do patrão, fruto de seu trabalho.

O réu Guilherme Araújo dos Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, confessou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Disse que foi pego no dia pois é viciado em crack e estava traficando para usar drogas. Às reperguntas da Defesa disse que o outro réu era cliente da "loja", sendo que não o conhece e não tem contato com o mesmo. Disse que continua fazendo tratamento para esquizofrenia.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa na audiência de instrução.

Pois bem.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O réu Guilherme confessou a prática delitativa, ao passo que o réu Cladauberto alegou ser usuário de drogas.

Anoto que a quantidade e a natureza da drogas apreendida (06 porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso bruto de 30,45g, 22 papелotes de cocaína com peso bruto de 28,16g, 43 microtubos de cocaína com peso bruto de 65,95g e 125 trouxinhas de papel de cocaína na forma de crack, com peso bruto de 32,32g), a forma de acondicionamento das substâncias, já individualizadas e embaladas, prontas para a venda e o consumo, o local onde se deram os fatos e o depoimento coeso e harmonioso dos policiais, evidenciam que eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o consumo próprio.

Ressalte-se que os policiais disseram que localizaram parte dos entorpecentes com os acusados e o restante no terreno. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSP Ap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito

Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No que diz respeito à versão do réu Cladauberto prestada em juízo, durante seu exercício de autodefesa processual, esta restou isolada, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastada.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação dos acusados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Quanto ao réu Cladauberto:

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando os maus antecedentes (fls. 62/68), fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, ainda que significativa e desvaliosa, somente será sopesada na terceira fase, a fim de evitar indevido bis in idem.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico ser inaplicável ao presente caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a existência de indícios concretos de que o acusado se dedica às atividades criminosas, considerando a reincidência do acusado, pelo que consta de sua folha de antecedentes já mencionada. Ausentes demais causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, devido a gravidade em concreto do crime, delito equiparado a hediondo, bem como pela reincidência, circunstâncias judiciais negativas e preponderantes, que não recomendam a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei nº 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do artigo 387, § 2º, Código de Processo Penal.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Quanto ao réu Guilherme:

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, dado que não ostenta maus antecedentes, conforme FA de fls. 71/72. A quantidade e natureza das drogas

apreendidas, ainda que significativa e desvaliosa, somente será sopesada na terceira fase, a fim de evitar indevido bis in idem.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da confissão. Mas a pena já está no mínimo e não pode ficar aquém do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade das acusadas e a ausência de indícios concretos de que se dedicassem às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Diminuo a pena na fração mínima de 1/6, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, com elevado potencial de causar dependência química aos seus usuários ((STJ, AgRg no REsp 1.902.218, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021), resultando assim a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena. Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência:

I - Condeno o acusado CLADAUBERTO LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

II - Condeno o acusado GUILHERME ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de 04 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 416 dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus.

Denego ao réu CLADAUBERTO LIMA DA SILVA o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos fundamentos ratifico nessa oportunidade. Considerando ainda as circunstâncias judiciais negativas já mencionadas na dosimetria da pena, a custódia cautelar do réu permanece necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação - TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Com relação ao réu GUILHERME ARAÚJO DOS SANTOS, concedo ao mesmo o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar. Expeça-se alvará de soltura com urgência. Os réus não apresentaram prova da origem lícita dos valores com eles apreendidos, razão pela qual decreto sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal dos réus, expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas.

Cumpra-se

Condeno os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.
Sao Sebastiao, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA